Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 18ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810321

Processo n° **0091567-46.2021.8.17.2001**

AUTOR: ARTUR OSCAR DA SILVA

RÉU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

SENTENÇA

Vistos etc.

ARTUR OSCAR DA SILVA, qualificado na petição inicial, através de advogado com procuração nos autos, promoveu a presente AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA em face de **CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL,** também qualificada na exordial**.**

Afirma a parte autora que é portador de câncer de próstata, desde 2000, tendo sido submetido a radioterapia. A partir de 2010, apresentou falha bioquímica e passou a fazer uso de ZOLADEX. Em 2013 passou a tomar Bicalutamida em face da elevação de PSA, com sucessivos aumentos de dose ao longo dos anos, o que caracteriza doença em progressão.

Tendo sido encaminhado ao radioterapeuta, foi contraindicada a radioterapia, assim como o urologista contraindicou a cirurgia devido ao risco de sequelas graves. Em maio/2018, iniciou a tomar Enzatutamida, mas desde agosto/2019 vem apresentando elevação lenta do PSA. Em razão disso, o médico assistente propôs a mudança de medicamento do Enzatutamida para o DORALUTAMIDA (Nubeqa), que tem efeitos adversos mais bem tolerados.

Salienta que a ANVISA aprovou o uso de DORALUTAMIDA para o tratamento de câncer de próstata, conforme faz prova o documento ID nº 90133375. Apesar disso, houve a negativa do plano de saúde demandado (ID nº 90133373), sob a alegação de ausência de cobertura contratual e por não constar no rol da ANS, RN nº 465/2021.

Afirmou não ter interesse na realização da audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC.

Requereu a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que a parte ré seja compelida a arcar com todas as despesas inerentes ao fornecimento da medicação para câncer DAROLUTAMIDA 300 mg 2x ao dia e tudo que vier a necessitar até o restabelecimento da saúde do autor, sob pena de multa diária. No mérito, requereu a procedência da ação, com a confirmação da tutela provisória de urgência, a condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais, nas custas processuais e nos honorários advocatícios. Apresentou documentos diversos.

Tutela antecipada negada na decisão de ID n° 90238809.

A parte demandante ingressou com pedido de reconsideração da liminar.

Em seguida, comunicou nos autos a decisão prolatada em sede de Agravo de Instrumento, no qual restou deferida a tutela recursal para custeio do medicamento DORALUTAMIDA (Nubeqa) pela agravada, a CASSI.

Em seguida, a seguradora demandada ofereceu contestação, alegando preliminar de impossibilidade de formulação de pedido genérico, e, no mérito, que é entidade fechada de previdência complementar que opera planos de saúde na modalidade de autogestão e sem fins lucrativos, sendo assim, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Invocou a aplicação da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Assevera que não está obrigada a autorizar o tratamento com a medicação DORALUTAMIDA (Nubeqa), eis que esta não consta no rol da ANS, segundo a RN 465/2021.Em razão disso, o medicamento não teria cobertura obrigatória pelos planos de saúde, não havendo a prática de ilícito em negar a cobertura do referido medicamento. Fundamenta suas alegações na Lei nº 9.656/98. Alega, inclusive, que o rol da ANS é taxativo.

Impugnou o pedido de indenização de danos morais e requereu a improcedência da ação. Acostou documentos aos autos.

Em seguida, a CASSI peticionou nos autos para requerer a juntada do comprovante de entrega do medicamento e sua nota fiscal, em cumprimento à decisão interlocutória que concedeu a tutela recursal, ID nº 93464834. Juntou documentos.

Réplica pela parte autora (ID n° 98732208).

Em sequência, foi anexado o acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça, dando provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela autora, confirmando a decisão que concedeu liminarmente a tutela recursal, autorizando o custeio pela CASSI do medicamento DORALUTAMIDA (Nubeqa) em favor do autor (ID nº 99703336). A demandada informou o cumprimento da liminar e juntou comprovante de compra do medicamento em questão.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

O feito se encontra pronto para o julgamento, uma vez que não necessita de produção de provas em audiência, motivo pelo qual promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia da lide se consubstancia na negativa do fornecimento do medicamento antineoplásico DORALUTAMIDA (Nubeqa) 300 mg 2x ao dia, tratamento contínuo, em benefício da parte autora.

1. DA PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO

No CPC/2015, a possibilidade jurídica do pedido consiste em decisão de mérito, sem natureza de pressuposto processual.

Aliás, não há mais menção àquela como hipótese de inépcia da petição inicial (art. 330, §1º do CPC). Também não há menção a ela no art. 485, VI do CPC, que apenas se refere a legitimidade e ao interesse de agir.

Além disso, no caso concreto, o autor especificou seu pedido, o custeio pelo plano de saúde de medicamento DORALUTAMIDA (nubeqa) em seu favor, sob pena de risco de vida.

Indefiro, pois, a alegação de impossibilidade de pedido genérico.

DO MÉRITO

DA NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS PLANOS DE SAÚDE ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO

Conforme alegado pela parte ré em sua defesa, restou pacificado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça a não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão.

É o caso dos planos de saúde oferecidos pela CASSI, operadora de saúde demandada, que são planos próprios destinados aos servidores públicos federais. Nestes planos de saúde, inexistem fins lucrativos e não há obrigatoriedade do oferecimento do plano referência.

Embora não sejam aplicáveis as normas consumeristas aos planos de saúde de autogestão, as cláusulas contratuais devem ser analisadas com base nos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato, além do princípio constitucional da dignidade humana.

DA NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE

A negativa de fornecimento do medicamento pelo plano de saúde restou comprovada, mediante a alegação de inexistência de previsão no Rol da ANS.

A matéria controvertida nos autos vem tratada na Lei dos Planos de Saúde. O art. 12 (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11332262/artigo-12-da-lei-n-9656-de-03-de-junho-de-1998), I (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11332229/inciso-i-do-artigo-12-da-lei-n-9656-de-03-de-junho-de-1998), c (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/27218017/alinea-c-do-inciso-i-do-artigo-12-da-lei-n-9656-de-03-de-junho-de-1998) da Lei nº 9.656 (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033833/lei-9656-98)/98, prevê a realização de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral como procedimento de cobertura mínima obrigatória pelos planos de saúde que incluem atendimento ambulatorial.

Da mesma forma, o art. 18, X, da Resolução Normativa nº 428/2017, da ANS, vigente à época da distribuição da presente ação, determina como cobertura básica para os planos privados de assistência à saúde o fornecimento de medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso.

Além disso, não havendo exclusão de cobertura para o tratamento de câncer, bem como sendo previsto o fornecimento de medicamentos antineoplásicos orais, mesmo para tratamento domiciliar, não há como afastar a cobertura de medicamento expressamente indicado pelo médico que acompanhava a paciente.

2.2. DO ROL TAXATIVO DA ANS

Recentemente, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº 1.889.704 entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS, estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. Contudo fixou parâmetros para mitigá-la em situações excepcionais, a fim de que os planos sejam obrigados a arcar com o custo de tratamentos não previstos na lista da ANS. Por exemplo, terapias que tenham comprovação de órgãos técnicos e a aprovação de instituições que regulam o setor, entre outras.

Coadunando com este entendimento, vale destacar, ainda, que a Lei nº 14454/2022 alterou a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9656.htm), para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

Acrescentou a redação do art.10, §13 à Lei dos Planos de Saúde, determinando o que segue:

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)

Assim sendo, o medicamento postulado está registrado na ANVISA e foi inserido no Rol da ANS atualmente em vigor, a RN 465/2021. Senão vejamos:

Detalhe do Produto: NUBEQA

Nome da Empresa Detentora do Registro	BAYER S.A.	**CNPJ**	18.459.628 (https://cor cnpj=1845
Processo	25351.317240/2019-18 (https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351317240201918/)	**Categoria Regulatória**	Novo
Nome Comercial	NUBEQA	**Registro**	170560120
Princípio Ativo	DAROLUTAMIDA		
Classe Terapêutica	ANTIANDRÓGENOS		
Parecer Público	Acesse aqui (https://consultas.anvisa.gov.br/#/pareceres/q/?nomeProduto=NUBEQA)		
Rotulagem			

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	300 MG COM REV CT FR PLAS PEAD OPC X 120 ATIVA	1705601200013	Comprimido Revestido	23/12/2019	36 meses

Fonte: http://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351317240201918/?nomeProduto=NUBEQA

Portanto, estando o medicamento NUBEQA registrado ns ANVISA, entende-se por preenchido o requisito da eficácia comprovada, exigido pelo art. 10, §13, inciso I da Lei dos Planos de Saúde, com a nova redação dada pela Lei nº 14454/2022.

Por todo o exposto, mostra-se abusiva a negativa do plano, motivo pelo qual deve ser julgada procedente a presente demanda, confirmando-se a tutela antecipada anteriormente concedida, devendo o plano de saúde arcar com o pagamento das despesas decorrentes do tratamento com a medicação DORALUTAMIDA (Nubeqa) em favor da autor.

DOS DANOS MORAIS

Quanto ao pedido de danos morais, ficou evidente a existência de dano à personalidade do autor, que se viu impossibilitada de obter o tratamento adequado, em momento que era necessário pronto atendimento, uma vez que foi acometido de doença grave e de progressão conhecida pela Medicina.

Evidencia-se, portanto, a configuração do dano moral, seja de ordem objetiva, em razão da violação ao direito personalíssimo à integridade física, seja de ordem subjetiva decorrente da sensação de angústia e aflição psicológica em situação de fragilidade já agravada pela doença.

Assim, constatados o dano, a conduta ilícita e o liame entre tais elementos, a compensação da lesão é medida que se impõe.

Acerca da matéria, eis o entendimento da jurisprudência dominante:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (STIVARGA REGORAFENIBE 40MG). DANO MORAL. *Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença reformada.* ***Fornecimento de medicamento.*** *Remédio indicado para tratamento quimioterápico da autora. Negativa de cobertura por expressa exclusão contratual. Existência de indicação médica. Impossibilidade de negativa (Súmulas 95, 102, TJSP; Enunciados 20, 29, 3ª Câmara de Direito Privado).* ***Dano moral.*** *Configuração. Negativa indevida de custeio de medicamento gera dano moral. Indenização majorada para R$ 10.000,00.* ***Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o da ré.*** *(TJSP; Apelação Cível 1002737-58.2020.8.26.0001; Relator (a): Carlos Alberto de Salles Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 09/02/2021)*

Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Autora portadora de "neoplasia maligna do cólon sigmoide", com metástase hepática. Negativa de fornecimento do medicamento "REGORAFENIBE" para tratamento quimioterápico. Medicamento registrado na ANVISA. ***Recusa de fornecimento indevida. Irrelevância da ausência de previsão no rol de procedimentos obrigatórios da ANS ou do não preenchimento das diretrizes de utilização daquela agência reguladora. Aplicação das Súmulas nºs. 95 e 102 do TJSP*** *. Dano moral "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 15.000,00. Valor que está adequado às circunstâncias do caso concreto, bem como à norma do art. 994* (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10673073/artigo-994-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002) *caput do CC* (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028078/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02) *e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Descumprimento da tutela provisória de urgência que deve ser dirimido em cumprimento de sentença. Recurso da autora parcialmente provido para conceder a pretendida reparação por danos morais. Recurso da ré desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000378-04.2018.8.26.0132; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 23/06/2020).*

O TJPE também já sumulou o entendimento, veja-se:

> **SUMULA 35:** A NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CLÁUSULA ABUSIVA DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PODE DAR ENSEJO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Contudo, a indenização deve ser fixada sem excessos, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, com base nessas premissas, tenho por bem fixar os danos morais em **R$ 7.000,00 (sete mil reais),** com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária pela tabela da ENCOGE, a partir da presente decisão.

3. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto e considerando o mais que dos autos constam, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, e, por consequência, tomar as seguintes providências:

a) <u>confirmar</u> a tutela antecipada antes deferida;

b) <u>condenar</u> a parte ré no pagamento de uma indenização, a título de danos morais devidos ao autor, no montante de **R$ 7.000,00 (sete mil reais)**, a ensejar incidência de juros de mora 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pela tabela da ENCOGE, a partir da data da publicação da presente de decisão;

c) <u>condenar</u> a demandada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação do item "b" acima.

P.R.I.

Recife, 16 de março de 2023.

ARNÓBIO AMORIM

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: ARNOBIO AMORIM ARAUJO JUNIOR
17/03/2023 18:20:13
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 128177303

23031718201297000000125230689

IMPRIMIR GERAR PDF